

1503238-46.2019.8.26.0079

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSIAS MARTINS DE ALMEIDA JUNIOR

Comarca: Botucatu

Foro: Foro de Botucatu

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/04/2022

... réu; é suficiente para definir a finalidade de tráfico.

Como é sabido, o delito de tráfico de drogas não exige, para a sua configuração, a venda propriamente dita do entorpecente.

Nesse sentido, confira-se:

"O crime de tráfico de entorpecente é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Botucatu

Foro de Botucatu

1ª Vara Criminal

PRAÇA IOLE DINUCCI FERNANDES, SEM Nº, Botucatu-SP - cep 18606-572

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1503238-46.2019.8.26.0079 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503238-46.2019.8.26.0079

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2365533/2019 - DEL.SEC.BOTUCATU, 9135478 - DEL.SEC.BOTUCATU, 1913/19/200 - DEL.SEC.BOTUCATU, 2365533 - DEL.SEC.BOTUCATU, 1913/19/200 - DEL.SEC.BOTUCATU, 2365533 - DISE- DEL.SEC.BOTUCATU, 1913/19/200 - DISE- DEL.SEC.BOTUCATU, 2365533 - DISE- DEL.SEC.BOTUCATU, 1913/19/200 - DISE- DEL.SEC.BOTUCATU, 2365533 - DISE- DEL.SEC.BOTUCATU, 1913/19/200 - DISE- DEL.SEC.BOTUCATU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOAO GABRIEL PEREIRA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSIAS MARTINS DE ALMEIDA JUNIOR

Vistos.

JOAO GABRIEL PEREIRA DA SILVA, qualificado nos autos, foi preso em flagrante delito, denunciado e viu-se processado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, artigo 129, "caput", e artigo 329, "caput", ambos do Código Penal, em concurso material, na forma do artigo 69, "caput", do mesmo Diploma Repressivo, porque no dia 18 de dezembro de 2019, por volta das 23h02min, na Rua Abigail Sampaio Faconti, via pública, altura do nº 80, Jardim Monte Mor, nesta cidade e comarca de Botucatu-SP, trazia consigo, para fins de entrega ao consumo de terceiras pessoas, 65 (sessenta e cinco) porções de maconha, individualmente embaladas em material plástico, com peso líquido de 31,87g, 37 (trinta e sete) porções de cocaína na forma de 'crack', individualmente embaladas em material plástico, com peso líquido de 6,16g, e 34 (trinta e quatro) porções de cocaína, acondicionadas em microtubos do tipo 'eppendorf', com peso líquido de 5,04g substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 15), laudo de constatação provisória (fls. 19/25) e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 51/53) acostados aos autos.

Consta, ainda, dos mesmos autos de inquérito policial que, no dia 18 de dezembro de 2019, por volta das 23h02min, na Rua Abigail Sampaio Faconti, via pública, altura do nº 80, Jardim Monte Mor, nesta cidade e comarca de Botucatu-SP, JOÃO GABRIEL PEREIRA DA SILVA (qualificado às fls. 07 e 09) opôs-se à execução de ato legal, mediante violência exercida contra policiais militares, funcionários públicos competentes para executá-lo.

Consta, por fim, dos referidos autos de inquérito policial que, dia 18 de dezembro de 2019, por volta das 23h02min, na Rua Abigail Sampaio Faconti, via pública, altura do nº 80, Jardim Monte Mor, nesta cidade e comarca de Botucatu/SP, JOÃO GABRIEL PEREIRA DA SILVA (qualificado às fls. 07 e 09) ofendeu a integridade corporal do policial militar Juliano Henrique Olenk Bulhões, causando-lhe as lesões corporais de natureza leve descritas no laudo pericial que será oportunamente juntado aos autos (fls. 16).

Segundo o apurado, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, momento em que se depararam com o réu, que estava na companhia de um outro indivíduo não identificado, sendo que ao perceberem a presença dos policiais, fugiram para um matagal existente nas imediações, tendo o denunciado dispensado algo no chão, enquanto os militares seguiram no encalço dos fugitivos.

JOÃO GABRIEL foi alcançado pelos policiais, momento em que investiu contra eles, desferindo socos e chutes no policial militar Juliano Henrique Olenk Bulhões, na tentativa de se desvencilhar da abordagem. Em razão das agressões, o policial Juliano sofreu lesões corporais de natureza leve no antebraço esquerdo, na mão e na perna direita.

Em revista pessoal foram localizados, bolso esquerdo do acusado, quatro "malotes" contendo, separadamente, 40 porções de maconha (em 2 malotes), 20 porções de cocaína (em 1 malote) e 20 pedras de 'crack' (em 1 malote), além de outras 11 porções de maconha, que estavam soltas, enquanto no bolso direito da calça de JOÃO GABRIEL foram encontrados R\$ 51,00 em dinheiro, distribuídos em cédulas diversas, numerário oriundo do comércio ilícito (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 15, laudo de constatação provisória de fls. 19/25 e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 51/53).

Diligenciando pelo local em que o denunciado havia dispensado algo no chão, os policiais encontraram duas embalagens plásticas de "Chocolates M&M" e uma embalagem de cosmético, certo que elas acondicionavam 17 pedras de 'crack', 14 porções de maconha e 14 porções de cocaína (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 15, laudo de constatação provisória de fls. 19/25 e laudo de exame químico-toxicológico de

fls. 51/53).

Indagado acerca dos fatos, JOÃO GABRIEL admitiu aos policiais militares que as drogas lhe pertenciam e se destinavam à prática da traficância naquele local, não informando, contudo, quem seria o rapaz que estava em sua companhia no momento da chegada dos policiais e que conseguiu fugir da abordagem.

Realizada audiência de custódia em 19/12/2019, foi o flagrante convertido em preventiva (fls. 33/35).

O relatório final foi apresentado em 13/01/2020 (fls. 55/57).

A denúncia foi oferecida em 15/01/2020 (fls. 60/64).

Por decisão de 16/01/2020 foi determinada a notificação do réu (fls. 69).

O réu foi notificado (fls. 79), e apresentou resposta à acusação (fls. 77).

A denúncia foi recebida em 18/02/2020, sendo designada audiência de instrução e julgamento (fls. 110).

Foi proferida decisão pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo nos autos de Habeas Corpus (573.178/SP) concedendo a liberdade ao acusado com a imposição de medidas cautelares (fls. 138/148).

O Alvará de Soltura Clausulado foi devidamente cumprido em 18/05/2020 (fls. 155/158).

O réu foi citado (fls. 181/183).

Durante a instrução criminal foram ouvidas três testemunhas arroladas em comum pela acusação e defesa e, a seguir, o réu foi interrogado (mídia de fls. 184).

O MP apresentou memoriais escritos requerendo a condenação do réu nos termos da denúncia (fls. 228/246).

A defesa apresentou alegações finais escritas pugnando pela absolvição do acusado nos termos do art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente requereu o reconhecimento do tráfico privilegiado com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito e pleiteou os benefícios da assistência judiciária (fls. 250/264).

É o relatório.

Decido.

Primeiramente, recebo como aditamento à denúncia os memoriais de fls. 228/246, para que passem a constar os dispositivos neles mencionados, salientando que não há necessidade de manifestação do réu, pois já houve defesa acerca dos fatos mencionados na denúncia, os quais permanecem os mesmos. Anote-se.

Trata-se de ação penal pública incondicionada que se destina a apurar a responsabilidade do denunciado pela prática de condutas que, em tese, estariam a configurar os delitos de tráfico de drogas, lesão corporal leve e resistência.

Ao término da instrução criminal e após um atento exame das provas existentes nos autos, não há como se deixar de reconhecer que a materialidade e a autoria do crime descrito na denúncia restaram parcialmente comprovadas.

Nesse sentido temos: o auto de prisão em flagrante (fls. 01/02); o boletim de ocorrência (fls. 11/14); o auto de exibição e apreensão (fls.15); o laudo de constatação (fls. 19/25); o relatório (fls. 55/57); o prontuário médico de fls. 187/189; o laudo pericial de fls. 223/224; o laudo de exame químico toxicológico (fls. 51/53); os depoimentos das testemunhas, e a versão do acusado.

Interrogado em juízo o réu confirmou que estava com a quantia de R\$ 50,00 reais. Que trabalha como servente de pedreiro. Informou que foi até o local dos fatos para adquirir parangas de maconha para o seu consumo pessoal, uma vez que é usuário de drogas. Relatou que no momento em que estava adquirindo o entorpecente chegou uma moto com dois indivíduos que começaram a "jogar" o veículo encima do depoente e do outro indivíduo que estava com ele gritando "perdeu, perdeu". Informou que ficou assustado e por esse motivo correu. Relatou que não sabia que os indivíduos que estavam na moto eram policiais pois eles estavam descaracterizados. Afirmou que os policiais conseguiram abordá-lo e que em momento algum ofereceu resistência. Relatou que quando estava correndo pulou uma cerca e que acredita que o policial se machucou nesse momento porque ele também pulou. Informou que não tem outros processos criminais e não conhece os policiais que realizaram a sua abordagem. Confirmou que estava de calça no dia dos fatos. Relatou que estava na posse de 05 parangas de maconha no momento em que fora abordado e que teria comprado o entorpecente do outro rapaz que correu (essência do depoimento de fls. 184).

A testemunha Raphael Fernandes Borges relatou que na data dos fatos realizavam patrulhamento visando coibir o tráfico de drogas oportunidade em que adentraram, a pé, em uma viela. O réu e outro indivíduo ao avistarem a equipe empreenderam fuga sendo que o acusado, que estava de calça, dispensava algo enquanto corria. Seguiram no encalço do acusado e lograram êxito em apreende-lo sendo que fora necessário a utilização de força moderada para quebrar a resistência do mesmo. Em revista pessoal foi localizado na posse do réu certa quantia de maconha, cocaína e "crack" R\$ 50,00 em dinheiro. Afirmou que o acusado já era conhecido nos meios policiais e existiam várias denúncias ligando ele ao tráfico de drogas. Indagado, o réu confirmou o tráfico de drogas no local. Afirmou que o que possibilitou terem certeza de quem a pessoa que dispensou os objetos era o acusado foi o fato dele estar trajando causa ao passo que o outro indivíduo estava de shorts (essência do depoimento de fls. 184).

A testemunha Juliano Henrique Olenk Bulhões relatou que estavam em patrulhamento pelo Bairro Jardim Monte Mor momento em que decidiram fazer uma incursão a pé em uma viela existente haja vista que é de conhecimento a existência do tráfico de drogas naquele local. Visualizaram o acusado e mais um indivíduo que ao perceberem a presença dos policiais empreenderam fuga. Durante a fuga o acusado passou a dispensar objetos pela rua que foram recolhidos pelo policial Damaceno. Afirmou que conseguiu deter o acusado que passou a desferir socos e cotovelos no intuito de se evadir. Obtiveram êxito em quebrar a resistência dele e conseguiram algema-lo. Realizada busca pessoal foi localizada certa quantidade de entorpecente e dinheiro. Relatou que na data dos fatos o irmão do acusado, pessoa bem conhecida nos meios policiais pelo envolvimento com o tráfico de drogas, estava preso e o acusado estava ocupando o seu lugar na traficância. Indagado o acusado confirmou que estava realizando o tráfico no local. Afirmou que em decorrência da resistência ofertada pelo acusado sofreu lesões corporais no braço e no rosto. Relatou que os objetos dispensados pelo réu durante a fuga eram dois tubinhos de chocolate M&Ms e uma bola oca em que ela guardava o entorpecente. Por fim, informou que sofreu lesões no seu antebraço/cotovelo em decorrência de uma queda que tivera no momento da perseguição (essência do depoimento de fls. 184).

A testemunha Matheus Damaceno de Mello relatou que na data dos fatos estavam em conduta de patrulha pela Rua 13 do Bairro Monte Mor passando por uma viela até chegarem na Rua 14 onde havia denúncia de tráfico de entorpecentes, momento em que visualizaram dois indivíduos que ao perceberem a presença da guarnição empreenderam

fuga. O acusado estava trajando calça e durante a fuga dispensou três objetos. Afirmou que pegou as embalagens que o acusado havia dispensado. Relatou que o acusado resistiu a prisão. Informou que em revista pessoal foi localizado entorpecente e dinheiro. Afirmou que dentro da embalagem que o acusado dispensou encontraram 17 porções de "crack", 14 porções de maconha e cocaína e na posse do réu foi localizada mais droga. Por fim, informou que seu colega Bulhões ficou lesionado em decorrência da resistência oferecida pelo acusado que no momento da abordagem desferiu socos e cotoveladas no policial (essência do depoimento de fls. 184).

Tem-se assim que o réu negou os fatos a si imputados, alegando que fora até o local dos fatos para adquirir entorpecente para seu consumo pessoal, uma vez que é usuário de drogas.

Todavia, em que pese a negativa do acusado as provas produzidas nos autos são suficientes para uma condenação segura do réu.

Os policiais militares foram uníssomos em afirmar que estavam em patrulhamento, a pé, por uma viela conhecida pela traficância, momento em que o acusado e outro indivíduo empreenderam fuga após perceberem a presença da guarnição.

Saíram ao encalço dos indivíduos, mas lograram êxito em apreender apenas o acusado que resistiu a prisão desferindo socos e cotoveladas no policial Juliano, causando-lhe lesões corporais.

Em revista pessoal lograram êxito em encontrar entorpecentes e dinheiro.

Por fim, relataram que dentro dos objetos dispensados pelo acusado durante a fuga foram localizados mais entorpecentes.

Anoto ainda que os policiais relataram que o acusado era conhecido dos meios policiais, possuindo denúncia de tráfico de drogas em relação a ele, bem como por ser irmão do indivíduo "Rafinha", conhecido por ser o gerente do tráfico naquela região.

Ora, a quantidade de droga apreendida, sua forma de acondicionamento, as embalagens e a quantidade de dinheiro encontradas na residência, tudo comprova a atividade de tráfico que era desenvolvida pelo acusado naquele local.

O acusado, por sua vez, não trouxe nenhuma prova a confirmar as suas alegações.

O Juiz de Direito, analisando a questão no contexto, observada a livre convicção motivada, deve decidir segundo sua consciência, buscando o alcance das verdadeiras finalidades das Leis.

Nesse diapasão:

"PERANTE O NOVO DIREITO BRASILEIRO, O JUIZ CRIMINAL É CHAMADO A EXERCER O SEU NOBRE OFÍCIO COM A SUA PRÓPRIA CONSCIÊNCIA, COM SEU PRÓPRIO RACIOCÍNIO, COM SUA LIVRE CRÍTICA. JÁ NÃO SERÁ UM INTÉRPRETE ESCOLÁSTICO DA LEI, UM APLICADOR DE JUSTIÇA TARIFADA, UM ÓRGÃO AUTOMÁTICO DE FÓRMULAS SACRAMENTAIS, MAS UMA CONSCIÊNCIA LEVRE A REGULAR DESTINOS HUMANOS" (TACRIM-SP - Rel. VALENTIN SILVA - RT 501/307).

Os depoimentos dos policiais são coerentes. A quantidade de droga apreendida; a forma do seu acondicionamento; e a fantasiosa versão apresentada pelo réu; é suficiente para definir a finalidade de tráfico.

Como é sabido, o delito de tráfico de drogas não exige, para a sua configuração, a venda propriamente dita do entorpecente.

Nesse sentido, confira-se:

“O crime de tráfico de entorpecente é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples possibilidade de distribuição (gratuita ou onerosa) do entorpecente” (RT 776/663).

Ainda:

“Não é dispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido”. (RT 729/542).

Fica bem tipificada a conduta prevista no artigo 33, “caput”, da Lei de Tóxicos.

Diante da possibilidade da livre convicção motivada, lembremos que em se tratando de delitos clandestinos, a força dos indícios não pode ser desprezada. A respeito, vale anotar:

“PROVA INDICIÁRIA – FORÇA PROBANTE – NO QUE INTERESSA AO DIREITO PROCESSUAL, A FORÇA PROBANTE DOS INDÍCIOS É IGUAL À DE QUALQUER OUTRO MEIO DE PROVA – SE O ESPÍRITO HUMANO, NA MAIORIA DAS VEZES, NÃO ATINGE A VERDADE SENÃO POR ARGUMENTOS PROBATÓRIOS INDIRETOS, PARA EVIDENCIAR A CIRCUNSTÂNCIA IGNORADA COM O NEXO DE CAUSALIDADE, OU DE IDENTIDADE ESPECÍFICA, NÃO PODERIA, POIS, SER DESPREZADA, NOS JUÍZOS CRIMINAIS, A PROVA INDICIÁRIA, DÊS QUE CADA VEZ MAIS A INTELIGÊNCIA, A PRUDÊNCIA E A CAUTELA DOS CRIMINOSOS DIFICULTAM A PROVA DIRETA” (RT 728/478).

A prova coligida é firme e segura a evidenciar a prática do tráfico de drogas pelo acusado.

Outrossim, o laudo de fls. 51/53 resultou positivo para cocaína, cocaína em forma de “crack” e maconha.

Conjunto probatório fortíssimo, não fica margem alguma para a desclassificação do tipo penal para a figura do artigo 28 da nova lei.

Não fica nenhuma dúvida para o julgador quanto à materialidade do delito e a destinação de tráfico daquelas drogas. Pontuo, ainda, que o tipo penal é de ação múltipla e conteúdo variado, estando bem tipificada a conduta pelo fato de o réu trazer consigo drogas, para aqueles fins.

Por outro lado, compulsando os autos entendo que a absolvição, na forma do artigo 386, VII, em relação ao delito de resistência é de rigor. Explico:

Pois bem, os policiais militares foram uníssomos em informar que, no momento da abordagem, o acusado ofereceu resistência ao cumprimento de ordem legal, desferindo socos e cotoveladas no policial Juliano.

Todavia, em relação ao delito de resistência, como se observa, não ficou claro no que ela consistiu, ou seja, se foi efetiva, ativa, consistente em agressão contra o policial, ou se foi passiva, apenas no sentido de evitar a detenção, sem agredir diretamente o agente da lei. Esta última situação determina a chamada resistência “passiva”, que não caracteriza o crime, pois existe a intenção não de agredir, mas de evitar, de alguma forma (não agredir), a detenção. Como ficou incerta a situação, nenhum dos policiais sendo específico a respeito, inexistindo prova produzida adequada, a absolvição, na forma do artigo 386, VII, é de rigor.

Por outro lado, essa conduta, ainda que não diretamente direcionada ao policial vítima, provocou, nele, lesões, conforme laudo pericial de fls. 223/224. A conduta é de dolo eventual, porque, daquela forma, assumiu o risco de provocar lesões, surgindo o resultado, como atestado em laudo de exame de corpo de delito. Deste modo faz-se necessária a condenação no delito de lesão corporal.

Assim, não resta dúvida de que no dia, horário e local descrito na denúncia, o acusado trazia consigo drogas, para fim de tráfico ilícito, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, bem como ofendeu a integridade corporal do policial militar Juliano Henrique Olenk Bulhões, causando-lhe as lesões corporais de natureza leve.

Nesse sentido:

"PENAL. APELAÇÃO. RESISTÊNCIA. LESÃO CORPORAL. DESACATO CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. Pretendida absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, absorção dos delitos de desacato e lesão corporal pelo crime de resistência e, em relação ao delito de desacato, a absolvição em virtude da incompatibilidade com o artigo 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos e da sua não recepção com o ordenamento constitucional. Requer, ainda, a fixação do regime aberto para início de cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 1. Absolvição. Possibilidade apenas para o crime de resistência. Crime de lesão corporal. Dolo eventual. Conduta de resistência contra a detenção por parte de indivíduo, o qual assume o risco de provocar lesões nos policiais que atuam em plena legalidade. Materialidade e autoria que restaram demonstradas pelos depoimentos dos policiais militares, bem como pelo exame de corpo de delito, cujo teor atesta que um dos policiais sofreu lesões corporais de natureza leve. Crime de desacato, restou demonstrado nos autos que houve ofensas perpetradas pelo apelante, com expressões de menoscabo e de baixo calão, comprovada a intenção de humilhar e desprestigiar funcionário público no exercício da função. Crime legitimamente tipificado, contra a moral do indivíduo e que reflete na Administração Pública, tornando-o diferenciado, perfeitamente adequado frente a Constituição Federal e em nada ofensivo aos direitos humanos. Impossibilidade de aplicação do princípio da consunção. Condutas provenientes de desígnios autônomos, alcançando diferentes bens jurídicos tutelados. Crime de resistência. Dúvida sobre existência de efetiva agressão contra os agentes da lei, ou seja, com resistência ativa. Possibilidade de mera resistência "passiva", visando apenas evitar prisão, não agredir ou lesionar, assumindo o agente, no entanto, o risco dos resultados. Absolvição de rigor. Artigo 386, VII, do CPP. 2. Alteração do regime determinado para início de expiação. Inviabilidade. Com razão a fixação do regime semiaberto para o início de cumprimento da pena, uma vez que se tratando de crime apenado com detenção e diante da comprovada reincidência do acusado, impõe-se a fixação de regime inicial mais gravoso para o cumprimento de pena, in casu, o semiaberto. 3. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Impossibilidade. Por ser reincidente, surgindo, no caso, insuficiente como reprimenda, corretamente não foi substituída a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos (artigo 44, II e III do Código Penal). Parcial provimento." (de Apelação Criminal nº 0008908-02.2016.8.26.0482, a 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, São Paulo, 17 de março de 2022).

As condutas encontram tipicidade na exata correspondência com o delitos definidos nos artigos 33, "caput", da Lei nº. 11.343/06 e artigo 129, §12, do Código Penal.

Inexistem causas que afastem a ilicitude das condutas, excluam a culpabilidade do denunciado ou extingam a punibilidade, razão pela qual reconheço a ocorrência do delito e passo a aplicar a pena.

A) Do delito do artigo 33, "caput", da Lei nº. 11.343/06:

Atento ao que estabelecem os artigos 59 do Código Penal e o artigo 42 da Lei 11.343/06, os motivos, as circunstâncias, a culpabilidade de elevada intensidade, a potencialidade, diversidade e quantidade de entorpecentes (65 porções de maconha, com peso líquido de 31,87g; 37 porções de cocaína na forma de 'crack', com peso líquido de 6,16g, e 34 porções de cocaína, com peso líquido de 5,04g), quantidade essa suficiente para a disseminação na sociedade, tudo a atingir a juventude e a motivar a criminalidade violenta que se tem visto na sociedade, outra solução não se mostra razoável a não ser a elevação da pena-base. Fixo, portanto, a pena-base acima do mínimo legal previsto para espécie em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, no valor mínimo legal.

Diminuo a pena em 1/6 tendo em vista a atenuante da menoridade relativa, perfazendo-se 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento 500 (quinhentos) dias-multa.

Não se vislumbram agravantes, bem como causas de aumento ou diminuição da pena.

O réu não faz jus ao disposto no artigo 33, §4º, da Lei nº. 11.343/06, pois a grande quantidade, diversidade de entorpecente, denúncias envolvendo o acusado com o tráfico de drogas, demonstram, por si só, o grau de envolvimento com o tráfico e que não se trata de "marinheiro de primeira viagem". Assim, o réu não pode ser tratado igual aos traficantes neófitos, que tem ao seu favor a causa de diminuição de pena acima mencionada. Entender de forma contrária seria no mínimo ferir o princípio da isonomia, e dar um tratamento benéfico àqueles que traficam em larga escala, algo não pretendido pela Lei 11.343/06.

Nos termos do referido dispositivo legal, entendo que o magistrado poderá reduzir a pena fixada ao agente - de um sexto a dois terços - desde que este seja primário, não possua antecedentes criminais, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosas.

Cuida-se, pois, de faculdade que o Juiz de Direito usará ou não, tendo em vista as circunstâncias do caso concreto, e não direito subjetivo do acusado. Na aplicação do preceito o Juiz deve verificar, também, a culpabilidade do agente e as circunstâncias do crime, sem o que estará ferindo o princípio da individualização da pena. E, na hipótese vertente, repito, tendo em vista as circunstâncias que envolveram a prisão do réu, não há dúvidas de que se dedicava ao comércio ilícito de entorpecente e, portanto, ostenta periculosidade maior. Assim, inviável a diminuição de pena supramencionada.

Nesse diapasão, cumpre trazer à baila recente acórdão prolatado pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo, em autos sentenciados por este magistrado, assim ementado:

"APELAÇÃO. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM". POSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. PENA MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA, ANTE A EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES, EM RAZÃO DA FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231, DO STJ. AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/06. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME FECHADO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.

1. A remissão feita pelo Magistrado referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a Pareceres do Ministério Público ou, ainda, às informações prestadas por Órgão apontado como coator) constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir, tal como se verifica na espécie. Fundamentação "per relationem". Inexistência de afronta à norma constitucional insculpida no art. 93, IX, da Constituição Federal. Precedentes do STF (AI 825.520 AgR-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 31.05.2011; AI 814.640/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 02.12.2010; HC 92.020/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 21.09.2010; HC 101.911/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j.

27.04.2010; HC 100.221/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 04.05.2010; HC 94.384/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 02.03.2010; Emb. Decl. MS 25.936-1/DF, Rel. Min. Celso de Mello, j. 13.06.2007; HC 98.814/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 23.06.2009; HC 94.243/SP, Rel. Min. Eros Grau, j. 31.03.2009; HC 96.517/RS, Rel. Min. Menezes Direito, j. 03.02.2009; RE 360.037/SC, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 07.08.2007; HC 75.385/SP, Rel. Min. Nelson Jobim, j. 07.10.1997).

2. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas foram devidamente comprovadas. Substância entorpecente encontrada na posse do réu.

3. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 1ª Câmara Criminal Extraordinária Voto n. 3.999 - Apelação n. 0006177-49.2014.8.26.0079 3 civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade dos entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE, Rel. Min. Carlos Ayres Brito, j. 05.09.06; HC 73.518-5 Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96; HC 70.237, Rel. Min. Carlos Velloso, RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06.06.13; HC 177.980/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 28.06.11; HC 149.540/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 12.04.11; HC 156.586/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 27.04.10).

Outrossim, especificamente quanto aos guardas civis, incide a inteligência da Lei n. 13.022/14, que amplia a restrita interpretação que se havia do art. 144, §8º, da Constituição Federal, dando-lhes, dentre outras competências específicas, as funções de colaboração na apuração penal e na defesa da paz social. Logo, as Guardas Municipais (guardas civis) estão investidas na incumbência da garantia da paz social, atuando na prevenção da prática de crimes, podendo, inclusive, atuar de forma a impedir a sua ocorrência, ou no caso de flagrante, conferir meios para subsidiar a apuração do fato criminoso. Precedentes do STJ (HC 290.371/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 27.05.14; RHC 45.173/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 26.05.14; HC 109.105/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 23.02.10).

4. Pena mantida conforme fixada na Origem.

5. Impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal ante o reconhecimento de circunstâncias atenuantes. Entendimento da Súmula n. 231, do STJ.

6. Tem-se entendido, corretamente, frise-se, que a conduta social do réu, o concurso de agentes, a quantidade e a natureza da substância entorpecente, a variedade das substâncias entorpecentes, os petrechos utilizados pelo criminoso e as circunstâncias da apreensão da substância entorpecente servem, primacialmente, como amparo probatório para o reconhecimento da dedicação do réu à atividade criminosa. Precedentes do STF.

7. Regime inicial de cumprimento de pena para o crime de tráfico de drogas será o fechado, medida esta estabelecida em perfeita harmonia com o tratamento diferenciado e mais rígido conferido pela própria Constituição Federal aos crimes hediondos e equiparados (art. 5º, XLIII), não cumprindo ao Poder Judiciário analisar a conveniência e a adequação da política criminal do seu tratamento, matéria reservada ao Poder Legislativo, Órgão constitucionalmente competente para tanto.

8. Improvimento do recurso defensivo. (TJ/SP, Apelação Criminal n. 0006177-49.2014.8.26.0079, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Des. Relator Airton Vieira, julgado em 03 de fevereiro de 2016, grifei).

A pena restritiva de liberdade será cumprida em regime inicialmente fechado, consoante art. 2º., §1º., da Lei nº. 8.072/90, na redação dada pela Lei nº. 11.464/2007.

B) Do delito do artigo 129, "caput" e § 12, do Código Penal:

O acusado é primário. Por conseguinte, as circunstâncias elencadas no art. 59 do Código Penal não lhe são desfavoráveis, não havendo motivos para fixação da pena base acima do mínimo legal. Fixo-a em 03 (três) meses de detenção. Deixo de impor a pena exclusiva de multa, uma vez que não seria suficiente para a ressocialização do acusado e também por não existir informações de que ele teria condições financeiras de arcar com tal pagamento.

Deixo de reduzir a pena em razão da atenuante da menoridade relativa tendo em vista que a pena-base já foi fixada no mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

Majoro a pena em 1/3 tendo em vista a causa de aumento prevista no §12 do artigo em comento, perfazendo-se 04 (quatro) meses de detenção.

Não se vislumbram agravantes, bem como causas de diminuição da pena.

O regime inicial para o cumprimento da pena será o aberto.

Tendo em vista o montante da pena aplicada o acusado não faz jus a quaisquer benefícios.

Por força do concurso material de crimes, artigo 69 do Código Penal, a pena de reclusão deverá ser primeiramente executada.

Torno definitiva a pena em 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento 500 (quinhentos) dias-multa; e 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR JOAO GABRIEL PEREIRA DA SILVA, ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento 500 (quinhentos) dias-multa, no valor mínimo legal, por infração ao artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06; e 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, por infração ao artigo 129, §12, do Código Penal. Em seguida, ABSOLVO JOAO GABRIEL PEREIRA DA SILVA, da prática do delito previsto no artigo 329, "caput", do Código Penal, nos termos do artigo 386, VII, do CPP.

Decreto o perdimento do numerário e bens apreendidos (fls. 15), na forma do artigo 63 da Lei nº. 11.343/06, pois vinculados à prática do comércio ilícito, não havendo nos autos qualquer prova em contrário. Expeça-se o necessário, oportunamente.

Caso algum dos bens apreendidos não possuam qualquer valor comercial, deixo de decretar o seu perdimento e autorizo a sua DESTRUIÇÃO, nos termos dos artigos 25 a 28, da Portaria SENAD nº 01, de 10/01/2020. Expeça-se o necessário, oportunamente.

Expeça(m)-se certidão(ões) de honorários ao(s) defensor(es) dativo(s), conforme Convênio Defensoria/OAB, se o caso.

Transitada esta em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Nos termos do Provimento CSM nº 2482/2018 (DJE 24/10/2018, p. 02/03) e artigo 525 das Normas Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça, defiro a incineração das amostras guardadas para contraprova. Oportunamente, expeça-se o necessário.

Por fim, quanto à pleiteada assistência judiciária, verifico que a defesa não juntou aos autos nenhum documento que comprove a impossibilidade econômica do acusado.

Além disso, o réu é representado por defensor constituído, o que por si só, demonstra que não se encontram em situação de miserabilidade, de modo que indefiro o pedido formulado.

Custas na forma da lei.

P. R. I. C.

Botucatu, 25 de abril de 2022.

Josias Martins de Almeida Júnior
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA